

第 66 問

以下の事例における、甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。ただし、住居等侵入罪については検討しなくてよい。

- (1) 甲は、A大学への入学を希望し、一生懸命に勉強していたが、全く成績は振るわず、受験に合格する可能性は極めて低かった。しかし、何としてでもA大学に入学したいと思った甲は、乙に対してA大学の入試を代わりに受けてもらえないか頼んだ。乙は、甲が一生懸命に勉強しているのを見ていたため、これを承諾した。

乙は、甲と事前に立てた計画通り、A大学入試の当日、甲になりすましてA大学入試会場に行き、答案用紙に「甲」と記入して、解答し、答案を提出した。

- (2) 丙は、銀行から融資を受けようとしたが、担当者から連帯保証人を2人付けることが条件であると言われたため、丙の兄であるB及びCに連帯保証人になるよう依頼した。すると、Bは快諾してくれたものの、Cには断られてしまった。

Bは、連帯保証契約書を受け取って署名するのが面倒であったため、これを丙に依頼したところ、丙は、連帯保証契約書の署名欄に「B」と記入した（以下「連帯保証契約書①」という。）。

一方、丙は、C以外に連帯保証人になることを頼む人がいなかったことから、銀行の担当者から渡された連帯保証契約書に「C代理人丙」と記載した（以下「連帯保証契約書②」という。）。

後日、丙は、連帯保証契約書①及び②を、銀行の担当者に提出した。

銀行の担当者はこれらの書類を審査し、丙に対して融資を行った。

第1 小問(1)

1 甲の罪責

- (1) 乙に成立する下記私文書偽造罪(159 I)及び同行使罪(161 I)について、共同正犯(60)の成否が問題となる。
- (2) この点については、文書偽造罪は名義人が犯すことができない消極的身分犯であると解すると、消極的身分犯と65条の適用関係が問題となるが、消極的身分犯を「身分」(65 I)に含めないのが判例であるから、甲には上記各罪について、共同正犯が成立する(東京地判平10.8.19参照)。この点をクリアすれば、甲に共同正犯が成立することは明らかであるが、甲は実行行為を担当していないから、共謀共同正犯の成否については一言触れておく(【論点】共同正犯の成立要件(共謀共同正犯論) 司H20,H24,H27,H28,H29,R3,予H24,H27,旧H7-1,H14-1,H15-1,H18-1)。

総合 139 頁 論証 55 頁

なお、名義人を「試験現場で当該答案を作成した甲」と解する場合には、上記の点は問題とならない。

2 乙の罪責

- (1) 乙がA大学の入試において、答案用紙に「甲」と記入した点について、有印私文書偽造罪(159 I)の成否を検討すべきである。
- (2) 同罪の成否に当たって問題となるのは、答案が「事実証明に関する文書」に当たるかという点と(【論点】「事実証明に関する文書」(159 I)の意義)、名義人の「甲」が上記行為について承諾を与えている点である(【論点】名義人の承諾 司H29、【論点】作成者の意義)。

総合 279 頁 論証 143 頁

総合 273 頁 論証 142 頁

総合 270 頁 論証 138 頁

前者の点については、最決平6.11.29【百選Ⅱ89】が、「本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書……に当たる」として、これを肯定した。

後者の点については、同決定の原審(東京高判平5.4.5)が、傍論ながら、「本件各答案は、志願者本人の学力の程度を判断するためのものであって、作成名義人以外の者の作成が許容されるものでないことは明らかである」として、承諾の有無(又はこれに関する被告人の認識)いかに問わず、同罪を構成するとしている。

なお、名義人を「試験現場で当該答案を作成した甲」と解する場合には、名義人による承諾がなく、人格の同一性を損なうものであるから、当然に偽造罪が成立することになる。

- (3) 以上から、乙には有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する。

第2 小問(2)

1 連帯保証契約書①について

連帯保証契約書は、小問(1)で問題となった大学入試の答案のように、自署性が強く求められる文書ではないと思われるところ、これについては名義人であるBの承諾があるから、不可罰になる。

2 連帯保証契約書②について

いわゆる代理名義の文書作成と偽造罪の成否が問題となる（**論点** 代理名義の冒用 **論** 司H24,予R1、**論点** 「偽造」（155 I 等）の意義、**論点** 作成者の意義）。

この点について、判例（最決昭45.9.4【百選Ⅱ93】）は、「他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書は、その文書によって表示された意識内容にもとづく効果が、代表もしくは代理された本人に帰属する形式のものであるから、その名義人は、代表もしくは代理された本人であると解するのが相当である」として、名義人を本人とみて、有形偽造の成立を認める。一方で、学説では、無形偽造説（不可罰説）もあるが、「C代理人丙」を名義人とみて、有形偽造の成立を認める見解が有力である。

また、偽造罪の成立を認めた場合には、同行使罪も成立し、融資を受けた点については、詐欺罪（246 I）の成立を認めることもできるだろう。

総合 272 頁 論証 141 頁
 総合 270 頁 論証 138 頁
 総合 270 頁 論証 138 頁

第1 小問(1)について

1 乙の罪責

有印私文書偽造罪（159 I）の成否



「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事実を証明するに足りる文書をいう



あてはめ



「偽造」



名義人の承諾



文書の性質上、その名義人自身による作成だけが予定されている文書については、名義人の承諾は意味をなさない



あてはめ



「行使の目的」「署名」



有印私文書偽造罪成立



同行使罪（161 I）成立



牽連犯となる（54 I 後段）

2 甲の罪責

有印私文書偽造罪、同行使罪の共同正犯（60）の成否



消極的身分犯



否定説



共同正犯成立

第2 小問(2)

1 連帯保証契約書自体は、名義人自身による作成だけが予定されている文書ではない

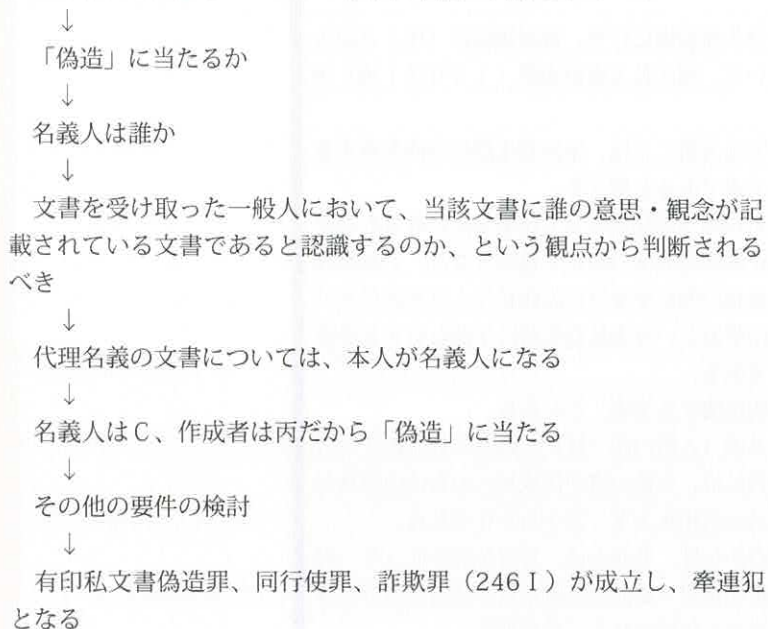


名義人Bの承諾がある以上、「偽造」には当たらない



連帯保証契約書①に「B」と記入した行為は「偽造」には当たらず、不可罰

2 連帯保証契約書②については、代理名義が冒用されている



第1 小問(1)

1 乙の罪責

(1) 甲になりすましてA大学入試会場に行き、答案用紙に「甲」と記入して、解答した行為について、有印私文書偽造罪（159条1項）が成立する可能性がある。

(2) まず、「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事実を証明するに足りる文書であると解する。

大学入試の答案は、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、その採点結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に可否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力という実社会生活に交渉を有する事実を証明するに足りる文書である。

したがって、「事実証明に関する文書」といえる。

(3) 次に、「偽造」とは、名義（人格の同一性）を偽ることを指すと考える。それが偽られた場合には、文書の真の作成者への責任の追及が困難となり、文書への社会の信頼を大きく害するからである。

そして、そのような観点からは、名義人は、文書を受け取った一般人において、当該文書に誰の意思・観念が記載されている文書であると認識するのかという観点から判断されるべきである。

本問において、答案用紙に記載された氏名は「甲」であるから、名義人は甲である。

一方で、乙は、甲の承諾を得て「甲」と記入している。

1

ここで、作成者とは、文書を作成させた意思の主体を指すところ、甲の承諾がある以上、作成者は甲となり、名義人と作成者の不一致は認められず、「偽造」には当たらないのが原則である。

(4) しかし、文書の性質上、その名義人自身による作成だけが予定されている文書については、別に考える必要がある。

このような文書では、名義人と作成者が同一でないと、名義人と作成者の人格の同一性に齟齬が発生してしまう。作成者と名義人の同一性が厳しく要求される場合だからである。

したがって、このような文書については、本人による名義使用の許諾は意味をなさず、人格の同一性を偽るものとして、「偽造」となるというべきである。

本問において、大学入試の答案は、上記のように志願者の学力を示す資料となるから、志願者本人による作成だけが予定されている文書である。そうだとすれば、甲による承諾は意味をなさない。

よって、人格の同一性を偽るものとして、「偽造」に当たる。

(5) さらに、乙には、入学試験の学力検査に当該答案を用いるという「行使の目的」があり、また、乙は、答案用紙に「甲」と記入していることから、「署名」を使用している。

以上から、乙には有印私文書偽造罪が成立する。

加えて、乙は答案を上記目的で提出しているから、これを「行使」したものとして、同行使罪（161条1項）が成立し、両罪は牽連犯となる（54条1項後段）。なお、後述のように、甲とは共同正犯

2

(60条)となる。

2 甲の罪責

- (1) 乙の有印私文書偽造罪、同行使罪について、共同正犯(60条)の成立が考えられる。

甲は乙による替え玉受験を計画した張本人であるから、乙と上記各行為(犯罪)について十分な意思連絡が認められ、また自己の犯罪としてこれに関与したといえる。そうだとすれば、「共同して犯罪を実行した」として、共同正犯が成立しそうである。なお、「実行」は共同正犯者のうち誰か一人が行えば足りるから、甲が実行行為を担当していないことは、共同正犯成立の障害とはならない。

- (2) もっとも、有印私文書偽造罪は名義人が犯し得ない消極的身分犯であるとも考えられる。このように考えると、この問題は65条の解釈に委ねられることになる。

しかし、同条にいう「身分」には消極的身分は含まれないと解すべきである。身分は、これを有することが特殊で、有しないことが通常でなければならないから、一定の身分にないという消極的事情が、身分になるということはないと解されるからである。そのため、65条の解釈問題とはならず、この点は共同正犯成立の障害とはならない。

- (3) 以上から、甲は、有印私文書偽造罪・同行使罪の共同正犯となる。

第2 小問(2)

- 1 連帯保証契約書①に「B」と記入した行為について、有印私文書偽造罪が成立するか問題となるも、連帯保証契約書は、名義人自身による作

3

成だけが予定されている文書ではないと思われるから、名義人たるBの承諾がある以上、作成者と名義人の人格の同一性は偽られていない。

したがって、上記行為は「偽造」には当たらず、同罪は成立しない。

- 2 連帯保証契約書②についてはどうか。

- (1) 丙はCによる許諾が無いにもかかわらず、これに「C代理人丙」と署名している。

- (2) 連帯保証契約書②は、代理名義の文書であるから、一般人は当該文書に現れた代理行為の効果が本人Cに帰属すると判断し、Cの意思・観念が記載された文書であると考えてるのが通常である。

したがって、連帯保証契約書②の名義人はCであるというべきである。一方で、Cによる許諾が無い以上、作成者は丙であるから、当該文書には名義人と作成者の不一致がみられる。

よって、「偽造」に当たる。

- (3) その他の要件について検討すると、連帯保証契約書は、「権利、義務……に関する文書」にあたり、銀行融資のために作成していることから、「行使の目的」も認められる。また、名義人Cの「署名」が用いられていることから、有印である。

- (4) 以上から、丙には連帯保証契約書②について、有印私文書偽造罪が成立する。融資担当者にこれを提出した行為については、同行使罪が成立し、融資を受けた点については、「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、詐欺罪(246条1項)も成立する。これらは目的手段の関係にあるから牽連犯(54条1項後段)となる。 以上

4